

1501908-33.2021.8.26.0535
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/08/2022

...

A testemunha Pedro afirmou que, em região conhecida pelo tráfico, avistaram o réu e ele passou a correr, largando uma sacola. Recolheram-na e conseguiram abordá-lo. Havia porções de entorpecentes na sacola e mais de R \$100,00 (cem reais) em poder do réu. Não se recordou se o dinheiro estava em suas vestes ou na sacola. Ele confessou prontamente que estava no tráfico há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
4ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501908-33.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501908-33.2021.8.26.0535
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2196198/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 19149965 - 01º D.P. GUARULHOS, 2340/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2341/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2196198 - 01º D.P. GUARULHOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO XAVIER DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Vistos.

GUSTAVO XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61,

inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 17h00, na Viela Hugo Zigler, nesta cidade e comarca de Guarulhos, qualificado fls. 12, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, trazia consigo, para fins de tráfico, 19 porções contendo 24,92g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha", 29 porções e 159 microtubos contendo, no total, 56,97g de cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação provisória a fls. 20/25.

A denúncia foi oferecida (fls. 47/50). O réu foi notificado (fls. 51) e apresentou resposta à acusação (fls. 66/67). A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 70/71).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em alegações finais, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, manifestou-se pela possibilidade de aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelo regime aberto e pela possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas.

A Defesa postulou a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do redutor, regime de cumprimento diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade processual ao réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria de delito ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), pelos boletins de ocorrência a fls. 03/08, pelo laudo de constatação provisória a fls. 20/25, pelo laudo do exame químico-toxicológico definitivo (fls. 63/65, positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol), e pela prova oral colhida.

A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas, o dinheiro apreendido (R\$ 190,00), a confissão e as circunstâncias da posse evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente indubitosa, considerando todo o conjunto probatório.

O réu confessou plenamente à prática delitiva, negando ser usuário. Salientou que teve apenas passagem como menor e está trabalhando. A confissão encontrou sólido respaldo probatório.

A testemunha Pedro afirmou que, em região conhecida pelo tráfico, avistaram o réu e ele passou a correr, largando uma sacola. Recolheram-na e conseguiram abordá-lo. Havia porções de entorpecentes na sacola e mais de R \$100,00 (cem reais) em poder do réu. Não se recordou se o dinheiro estava em suas vestes ou na sacola. Ele confessou prontamente que estava no tráfico há poucos dias. Respondeu à defesa que não conhecia o réu.

O policial Luiz Fernando confirmou que o réu se assustou com a presença da polícia e passou a correr. Jogou uma sacola, que foi recolhida e que continha porções de

entorpecentes. Abordado, o réu prontamente confessou que estava no tráfico e que o dinheiro era proveniente das vendas. Não se recordou onde estava o dinheiro. Respondeu à defesa que não o conhecia e que o local é afamado pela venda de drogas.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. Na data aludida, o réu tentou se evadir ante a aproximação dos policiais civis, mas, após breve perseguição, foi abordado. Em sua posse estavam entorpecentes, dos quais tentou se desvencilhar. Indagado, confessou informalmente a traficância, confissão reiterada e corroborada em juízo.

Com efeito, observa-se que a confissão judicial encontrou sólido amparo nas provas produzidas. Não permaneceu isolada e foi corroborada por várias declarações. Nenhum dado concreto a abalou. Não há que se falar, portanto, em eventual insuficiência - por seu valor relativo - da confissão judicial, já que esta, no caso dos autos, está amparada por vários elementos probatórios, mormente depoimentos harmônicos. Nesse sentido, transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

"(..) a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto ela as transcende; elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada; transforma uma afirmação feita se ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal". (Código de Processo Penal Comentado, 12^a ed., São Paulo: RT, 2012, p. 470).

E no caso em apreço, os testemunhos atestaram, em uníssono, com detalhes, coerência e firmeza, a posse das drogas pelo réu, além da fuga sintomática e confissão, revelando plena adesão ao tráfico, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa convincente e não cogitou de motivo para ser supostamente incriminado falsamente. Não é crível, outrossim, que a quantidade de maconha e cocaína se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo em local público. Assim, não obstante os argumentos da Defesa, as provas da dinâmica dos fatos exposta na exordial são fartas, concluindo-se seguramente pela autoria e dolo.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico

de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada." (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente na palavra de policial, confissão ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial sobre a dinâmica da obtenção dos elementos sensíveis da infração, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

"(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto". (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

Nesse sentido, os relatos dos policiais devem prevalecer sobre a eventuais impugnações da defesa, pois foram coerentes nas duas fases processuais, minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos, a propósito, para incriminarem falsamente um desconhecido. Também não sugeriram indícios de que a droga pertencesse a outrem ou de equívoco ou ainda vício no flagrante.

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento da droga, a visualização de uma venda, a confissão espontânea e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei. O acusado é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica ou de vício, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não autorizam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a

dosimetria da pena, fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a primariedade.

Na segunda fase, prejudicada a análise da circunstância atenuante da confissão ou da menoridade relativa, ante a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

Não vislumbro presente a agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, pois o delito não tem relação direta com a pandemia e o agente não se aproveitou de circunstâncias decorrentes do período de excepcionalidade, como ocorreria com corrupção no setor de saúde, fraudes de licitações correspondentes e outras situações análogas. Entendimento contrário exigiria a incidência do aumento da pena sobre todas infrações, o que não condiz com a exegese teleológica e sistemática das normas do ordenamento pátrio sobre a matéria. A falta de nexo causal entre conduta do réu e pandemia e a ausência de satisfação dos fins de política criminal inerentes à previsão da agravante desaconselham o acolhimento do pedido do Parquet. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente infrator realizado em plena época da pandemia - Autoria e materialidade delitiva comprovadas quanto ao tráfico com envolvimento de adolescente - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Impossibilidade de admissão do tráfico privilegiado diante da prova colhida nos autos - Penas readequadas para se afastar o aumento na primeira fase diante da diversidade e quantidade, além da agravante presente com no artigo 61, inciso II, "j" do CP, diante da ausência do nexo de causalidade entre o fato praticado e o contexto da pandemia do Covid-19 em curso - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade - Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Criminal 1501582-16.2020.8.26.0533; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Na terceira etapa, tendo em vista a primariedade do réu, a confissão e a ausência de indícios de envolvimento em organização ou dedicação à atividade criminosa, adota-se a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/2, perfazendo 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despicando, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase.

Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade, variedade e a natureza de parte da droga (cocaína), não se exige a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução como simples benefício – que já pode ir aquém do mínimo legal – e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica das normas sobre a matéria, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto e a especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva. As confissões revelando sinceridade, disposição de se corrigir e algum arrependimento, a menoridade e a função do réu no tráfico (ausente prova de efetivo comando e gerência na região), por outro lado, não exigem a redução mínima.

Assim, para a pena de 2 anos e 6 meses definitiva, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento, tendo em vista o “privilégio”, a natureza do crime (sem violência ou ameaça que poderia exigir o fechado) e as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena, sem prejuízo da possibilidade de outro mais gravoso (aqui aberto) em razão de fatores específicos, ausentes no caso concreto. Sobre a temática, confira-se:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE”. (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Preenchidos, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do CP, à luz da pena aplicada e da primariedade, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena a uma entidade com função social, e prestação pecuniária de um salário mínimo, especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Órgão Ministerial para CONDENAR o réu GUSTAVO XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, na pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação gratuita de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade com função social, em condições especificadas na execução além de 250 dias-multa pelo valor unitário mínimo.

Ante a natureza da reprimenda, o réu poderá apelar solto.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União, ante as evidências do liame com o tráfico, e determino a incineração da droga apreendida.

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, deferida a gratuidade.
P.I.C.

Guarulhos, 08 de agosto de 2022.

Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA